



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3583 del Ruolo Generale per l'anno 2021

TRA

Parte_1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Delfinetti.

PARTE OPPONENTE

E

CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Parodi.

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato la parte opponente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, emessa dal Tribunale in data 25.3.2021 (R.G. n. 8721/20), con la quale è stato annullato il licenziamento impugnato ed è stata condannata la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria. Nel censurare tale ordinanza, l'opponente ha chiesto in questa sede:

*“a - accertare, dichiarare e confermare la legittimità, la validità e l'efficacia del licenziamento disciplinare irrogato da **Parte_1** nei confronti del sig. **CP_1** con ogni e conseguente provvedimento di legge che il Tribunale adito riterrà opportuno emettere;*

*b - in ogni caso respingere e rigettare tutte le domande formulate dal sig. [...] **CP_1** nei confronti di **Parte_1** nel ricorso sommario e nella presente fase di giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ut supra esposti”.*

La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese ed ha chiesto la conferma dell'ordinanza, riproponendo le doglianze già avanzate con il ricorso introduttivo della prima fase.

1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di improcedibilità del ricorso per tardività nella proposizione.

Ed invero, il ricorso in opposizione risulta depositato in data 23.4.2021, e dunque nel pieno rispetto del termine di legge.

2. In secondo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla parte opposta.

Ed invero, le deduzioni inerenti ai presupposti costitutivi delle domande attoree risultano chiare e, dal corpo dell'atto, risultano desumibili tutti gli elementi di fatto e diritto necessari alla delimitazione del *petitum* e della relativa *causa petendi*.

3. Venendo al merito della controversia, la difesa della società opponente ha innanzitutto sostenuto la legittimità del licenziamento irrogato, eccependo che:

- “il sig. **CP_1** non ha in alcun modo informato la propria datrice di lavoro dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico e delle limitazioni, riverberantisi sull'attività lavorativa ... Quindi, il sig. **CP_1** ha mentito più volte” (cfr. pag. 6 del ricorso in opposizione);

- “la circostanza che il sig. **CP_1** abbia tenuto condotte tali da giustificare un processo penale a suo carico e la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. appare di per sé idonea a far venir meno il rapporto fiduciario considerata anche la peculiarità del caso concreto: non è, infatti, da dimenticare che **Parte_1** è società che ha quale attività prevalente quella di servizi di sicurezza” (cfr. pag. 7 del ricorso in opposizione).

3.1. Le obiezioni rassegnate si presentano del tutto inconferenti poiché le condotte così descritte non sono state in alcun modo indicate nella lettera di contestazione disciplinare sottesa al recesso datoriale, nella quale si legge (cfr. all. n. 12 al ricorso introduttivo della prima fase):

Addebito: la S.V. è alle dipendenze della scrivente società sin dal 02 Novembre 2016, con mansioni di addetto all'attività di custodia, e con vincolo di esclusiva, come da contratto di assunzione. Sin dal **02 Maggio 2019** la S.V. ha chiesto ed ottenuto dalla scrivente azienda un congedo parentale, terminato in data 31 Agosto 2019 e che successivamente, sempre su Sua richiesta, si è prolungato sino al **31 Dicembre 2019**, a titolo di congedo straordinario per assistenza al coniuge disabile dal 01 Agosto 2019 sino al 31 Dicembre 2019, data in cui Lei dovrà riprendere servizio.

La scrivente Azienda ha verificato, mediante attività investigativa autorizzata per legge, lo svolgimento da parte Sua di altra attività lavorativa - irregolare - ed in particolare l'attività di pulizia da Lei svolta presso la ONLUS ALA di Via Boifava, 60/A, Milano, così violando gli obblighi di esclusività, correttezza e buona fede verso la scrivente, connessi e conseguenti al rapporto di lavoro, unitamente ai medesimi obblighi previsti per il regime di congedo parentale da Lei richiesti e di cui ha beneficiato dal 02 Maggio 2019 sino al 31 Agosto 2019 ed a titolo di congedo straordinario per assistenza al coniuge disabile, dal 01 Agosto 2019 sino al 31 Dicembre 2019. Ne discende che, allo stato degli atti e dei fatti così emersi *per tabulas*, il Suo comportamento configura la propria esclusiva inadempienza alle regole contrattuali e disciplinari che devono essere sempre rispettate dal dipendente.

Contestazione: la scrivente azienda Le contesta quindi i suindicati addebiti, che costituiscono gravissimo inadempimento contrattuale alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, più in particolare, violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 2104 del Codice Civile, oltreché di quanto espressamente previsto dal CCNL per i dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e violazione delle disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartiteLe dalla nostra Azienda.

3.2. Dunque, nella lettera di contestazione del 30.12.2019 viene esclusivamente addebitato al lavoratore il fatto di aver svolto *altra* attività lavorativa e di aver così violato gli obblighi di *esclusività*, correttezza e buona fede, unitamente agli obblighi previsti per il regime di *congedo* parentale.

Non si rinviene alcun riferimento alla dedotta omissione informativa o ai fatti di reato connessi al processo penale e alla messa alla prova.

3.3. L'assenza di queste contestazioni in sede di procedimento disciplinare basta a ritenere infondate le eccezioni dell'opponente riassunte nel motivo lett. A) in ricorso.

4. Quanto poi alla doglianza con cui l'opponente ha sostenuto che la prestazione di attività lavorativa *aliunde* dovrebbe comunque integrare una giusta causa di licenziamento, devono qui richiamarsi gli approdi raggiunti nell'ordinanza impugnata.

4.1. L'incompatibilità dell'attività oggetto di contestazione con l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della **Parte_1** è stata smentita dall'informatore **Testimone_1**, presidente dell **[...]** **Org_1** che ha ricordato come l'opposto aveva seguito un percorso di messa alla prova lavorando per l'associazione "1 o 2 giorni a settimana ... o dalle 9 alle 13 o dalle 13 alle 17,00",

presumibilmente quando aveva il giorno di riposo in relazione all'occupazione presso **Parte_1** e comunque sempre *“in funzione dei suoi turni di lavoro come guardia giurata”*.

In assenza di elementi contrari, deve quindi escludersi che l'attività in questione abbia potuto creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della società o comunque complicazioni nella sua organizzazione imprenditoriale.

4.2. Quanto al periodo di congedo parentale, l'esiguità della frequenza dell'impiego presso la Onlus (per come ricordata dall'informatore e non contrastata da altre evidenze) impedisce di integrare un'ipotesi di abuso per sviamento dalla funzione del diritto al congedo.

Ed invero, 4 ore al giorno per 1-2 giorni a settimana non appaiono un tempo di lavoro tale da frustrare il menzionato diritto, a scapito della cura diretta del bambino.

4.3. Venendo infine al paventato pregiudizio dello stato di salute del lavoratore, risulta incontrovertibile che lo stesso in data 13.2.2017, a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva sbattuto contro uno scaffale riportando un trauma contusivo alla spalla destra (come ricostruito nella sentenza penale del Trib. Milano n. 10399/2017 all. n. 8 al ricorso).

4.3.1. Stando alla tesi della società opponente, lo stato invalidante provocato dall'infortunio sarebbe incompatibile con l'attività svolta dal lavoratore presso l' **Organizzazione_1**

Al riguardo, l'informatore **Testimone_1** ha riferito: *“Il ricorrente per noi ha svolto attività di segreteria (fotocopie, etc) e interventi di piccola manutenzione (aggiustare porte, pulizia scrivanie, etc)”*.

Ora, per come descritta dall'informatore, la prestazione a cui era adibito l'opposto non risulta *ex se* ineseguibile da un soggetto che abbia subito un trauma contusivo alla spalla destra.

Né si rinvergono elementi da cui poter desumere con certezza che tale attività (svolta per 1-2 giorni a settimana per 4 ore) potesse ritardare la guarigione del lavoratore.

4.3.2. A ciò si aggiunga che il giudizio che viene in esame (malattia vera o simulata/non impeditiva) non può che fondarsi, se del caso acquisendo riscontri tecnici medico-legali, sul raffronto tra il tipo di malattia e l'attività in concreto svolta (cfr. Cass. nn. 586/2016, 17625/2014, 21253/2012, 15916/2000).

Tuttavia, le prospettazioni della **Parte_1** si basano su valutazioni prive di alcun sostrato medico-scientifico (e sulle quali apparirebbe inammissibile una prova per testimoni, in quanto valutativa).

E non può di certo bastare a colmare tale difetto dimostrativo il “Rapporto di servizio” allegato all'odierno ricorso in opposizione (all. n. 3).

Infatti, tale rapporto si compone di alcune fotografie che ritraggono l'opposto mentre pulisce con una scopa la sede dell' **Org_1** e il cortile esterno. Ma da esse non possono affatto dirsi riscontrate: l'effettiva regolarità dei movimenti, l'assenza di difficoltà, di limitazioni e di sofferenza nello svolgerli.

Elementi, questi, che si rivelano cruciali per poter confermare il preteso contrasto con il quadro clinico risultante dalla documentazione medica prodotta.

4.3.3. Nella presente fattispecie, dunque, ciò che risulta acquisito al processo è solamente che l'opposto aveva compiuto "*attività di segreteria (fotocopie, etc) e interventi di piccola manutenzione*" (come precisato dall'informatore) e si era occupato di spazzare e pulire i locali dell' Org_1 (come documentato dalle fotografie offerte dall'opponente), senza però alcuna specifica emergenza in ordine alle modalità con cui tali compiti sono stati espletati (ad esempio: se facendo costante ricorso alla spalla infortunata, se o meno in assenza di difficoltà o limitazioni nello svolgerli).

4.3.5. Non può, del resto, apparire revocabile in dubbio che gravi sul datore di lavoro l'onere di provare sia lo svolgimento dell'attività esterna sia le *caratteristiche* della stessa che la rendano illecita.

Ma nella lettera di licenziamento la società datrice di lavoro si è limitata ad affermare che le condotte rilevate (all'esito di indagini investigative) sarebbero di per sé tali da smentire lo stato invalidante in cui versava il lavoratore, senza però evidenziare gli specifici fattori di incompatibilità, desumibili dalle emergenze fattuali e avuto riguardo alla natura della lesione.

4.3.6. In forza del compendio istruttorio disponibile, non pare dunque possibile convalidare gli addebiti mossi all'opposto, in quanto non risulta emersa la fraudolenta simulazione della malattia.

Le condotte riassunte nella lettera di licenziamento, prive di valutazioni di carattere scientifico, non possono dirsi per ciò solo incompatibili con la patologia che affligge il lavoratore.

5. Da qui l'assenza di giusta causa del licenziamento, stante l'insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela ex art. 18, **co. 4**, St. lav.

5.1. Con riguardo a tale conclusione qualificatoria, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte nell'ordinanza impugnata.

5.2. Come è noto, invero, sulla nozione di "*fatto contestato*" si è incentrato il dibattito interpretativo dottrinale e giurisprudenziale all'indomani dell'entrata in vigore della novella di cui alla l. n. 92/2012 (in forza della quale, il comma quarto dell'art. 18 recita: "*Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione...*").

5.3. Ad avviso del Tribunale, la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione, non può che comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi - sia l'elemento oggettivo (condotta, anche omissiva, evento e nesso di causalità) che l'elemento soggettivo e l'antigiuridicità - alla luce della nozione di giusta causa rilevante nella fattispecie considerata.

Del resto, la ragione per cui tale fatto debba essere inteso come potenzialmente inclusivo anche di elementi "*non materiali*" può essere desunta dalla circostanza che nella norma l'insussistenza è predicata del "*fatto contestato*" come potenziale infrazione disciplinare, da valutare sempre in una con l'atto di

intimazione del licenziamento, per cui è doveroso prendere in considerazione anche gli altri elementi idonei a qualificare, nella prospettiva versata nella procedura dal datore di lavoro, l'antigiuridicità del fatto oggetto di contestazione.

In particolare, per quel che qui rileva, del fatto così inteso fa parte anche l'elemento dell'antigiuridicità disciplinare. Infatti, nella prospettiva della novella del 2012, il riferimento al fatto "*contestato*" implica che va ritenuto insussistente anche il fatto accaduto ma privo del carattere della rilevanza disciplinare, ossia quel fatto che, pur accertato, è del tutto irrilevante giuridicamente perché non suscettibile di alcuna sanzione.

5.4. Tale conclusione è stata affermata con limpidezza dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 20540-20545/2015, 18418/2016), che ha statuito che "*l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 St. Lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92/2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità*".

In una recente sentenza della Corte di Cassazione, avente ad oggetto proprio un caso di licenziamento per giusta causa fondato sulla contestazione di svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia, in cui il licenziamento era stato annullato con applicazione della tutela di cui al comma 4 dell'art. 18, è stata confermata la tutela applicata dal giudice di merito, affermando quanto segue: "*Questa Corte ha più in particolare chiarito che non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, restando estranea alla fattispecie la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n. 23669, che peraltro si riferiva ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole l'irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, cit.*" (cfr. Cass. n. 3655/2019).

5.5. Potendo, dunque, pacificamente affermare che ciò che rileva ai fini dell'art. 18, co. 4, St. Lav. è il fatto contestato inteso come fatto giuridicamente rilevante, nel caso di specie è possibile concludere che - risultando indimostrate l'incompatibilità dell'attività presso la *Org_1* con l'attività lavorativa svolta dal lavoratore per la società, l'incompatibilità con il congedo parentale o la fraudolenta simulazione della malattia o lo svolgimento di attività contraria alla pronta guarigione - il fatto contestato è privo di rilevanza disciplinare, in quanto sprovvisto del carattere di illiceità.

5.6. Accertato, quindi, che non ricorrono gli estremi della giusta causa del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, il licenziamento deve seguire la via dell'annullamento ai sensi dell'art. 18, co. 4, St. lav.

6. Pertanto, tutti i motivi rassegnati con l'opposizione devono essere respinti.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione;

- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 2.400,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore richiedente ex art. 93 c.p.c.

Milano, 02.03.2022

Il giudice
Franco Caroleo